

CLASE DE OBLIGACIONES

Responsabilidad

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

A) LA RESPONSABILIDAD GENERAL

1.- CONCEPTO

Sentidos del vocablo responsabilidad. La responsabilidad puede ser entendida en distintos sentidos:

(1) En una concepción amplia, se puede entender por responsable a todo el que debe cumplir. Se abarca así la conducta debida, y la sanción por no adecuarse a ella.

(2) O es dable calificar como responsable al deudor que no ha cumplido y está sujeto a las acciones del acreedor. Al no haber acatado el comportamiento debido como prestación, el acreedor tiene derecho a ejecutarlo forzosamente, obtener la ejecución por otro a su costa, o reclamarle indemnización. Este es el tramo de la responsabilidad que implica la actuación de mecanismos legales para que el acreedor se satisfaga de una u otra manera, en defecto de cumplimiento espontáneo por parte del deudor.

(3) O, en sentido estricto, se dice responsable a quien, por no haber cumplido con una prestación a su cargo, se le reclama indemnización. Esta es la acepción que comúnmente se da al concepto, en cuanto concierne al deber de reparar el daño jurídicamente atribuible causado por el incumplimiento.

Responsabilidad e imputabilidad. La responsabilidad moral.— Una acción es imputable cuando se la puede referir a la actividad de una persona; pero tal imputación no adelanta criterio acerca de la responsabilidad del sujeto. Un obrar es imputable a alguien cuando puede ser referido a su conducta; ese sujeto es moralmente imputable si obró voluntariamente: y sólo es jurídicamente responsable cuando lo ha hecho transgrediendo el ordenamiento jurídico.

Responsabilidad y carga.— En la relación jurídica, al derecho subjetivo, o facultad, de un sujeto, corresponde el correlativo deber de otro sujeto. El deber, pues, consiste en una conducta impuesta a un sujeto (pasivo), que otro sujeto (activo) tiene derecho a exigir coactivamente, y cuyo incumplimiento da lugar a una sanción: esto es, a una consecuencia de índole jurídica que corresponde a la infracción de un deber, y que significa un disvalor para quien es pasible de ella.

La obligación genera deberes, pero éstos consisten concretamente en satisfacer una prestación de contenido patrimonial. Mientras la deuda que existe en la obligación es un deber, no todo deber es una deuda: técnicamente sólo son denominados deudas los deberes de carácter relativo y de contenido patrimonial, a los cuales corresponde un derecho subjetivo creditorio.

La responsabilidad — a su vez —, en el ámbito del Derecho civil y en el área de las obligaciones, implica el deber de reparar, de satisfacer una prestación (patrimonial), a favor de la víctima de una infracción.

Ámbitos de la responsabilidad jurídica.— El Derecho tiene organizado todo un sistema de sanciones, algunas de las cuales son retributivas o represivas y otras resarcitorias. En la sanción represiva no hay equivalencia material entre la infracción y el mal inferido al autor, en tanto la sanción resarcitoria supone un principio de equivalencia entre el daño y la indemnización con la cual se lo repara.

La sanción retributiva o represiva — aun existiendo, en su medida en Derecho civil — es típica del Derecho penal. Hay, pues, una órbita propia de la responsabilidad penal.

Hay, además, y es la que especialmente nos interesa, una esfera de responsabilidad civil generadora de indemnización. En materia de obligaciones. La reparación civil consiste en una prestación que se impone al responsable de un daño injusto. Esta prestación es establecida en consideración a la cuantía del daño, que constituye su tope; aun en los supuestos de agravación del monto indemnizatorio en función del dolo, ese plus

no es debido de manera independiente de la medida exacta del perjuicio, sino como reparación del daño inferido. Tiene, pues, una concreta finalidad de satisfacción de la víctima por el victimario, a través de una prestación patrimonial, que se impone a este último a favor de aquélla.

2.- LOS PRINCIPIOS EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL

(1) ***Neminem laedere***. Principio que corresponde a uno de los contenidos del Derecho para los romanos: *neminem laedere* (**no dañar a nadie**): *alterum non laedere* (no dañar a otro). Es norma implícita de los sistemas que incriminan el daño injusto. Este *neminem laedere* rige con independencia de cualquier estipulación al respecto, por la mera convivencia social; es una garantía de paz en ella.

(2) **Se debe responder por actos propios, no ajenos**. Otro principio es el de la responsabilidad por actos propios: se responde por actos propios, no por actos ajenos. Esto aparece consagrado respecto de los actos positivos y de los actos negativos; atañe al problema de la causalidad como respuesta a quién o qué ha desencadenado un consecuente; y rige, inclusive, en la responsabilidad indirecta en que, por lo general, hay como subsuelo cierta acción u omisión de la persona en quien se refleja la responsabilidad y a quien se le exige el deber de reparar.

(3) **Imputabilidad subjetiva**. Clásicamente ha sido sostenida la vigencia de un principio de imputabilidad subjetiva, según el cual no hay responsabilidad sin culpabilidad; a la vez que no puede haber culpabilidad sin que el acto principie por ser voluntario en sentido jurídico, esto es, obrado con discernimiento, intención y libertad. En efecto, si culpable es quien obra sin la debida diligencia, va de suyo que su ligereza de proceder lo hace moralmente reprochable.

En la actualidad es evidente la tendencia contraria, es decir, la atribución de responsabilidad con criterio objetivo, fundada en la mera causalidad material, sin que sea exigido un desajuste de conducta en grado genérico de culpa, o en grado específico de dolo. El CCyCN introdujo claramente esos conceptos. Así los artículos de expresan:

ARTÍCULO 1722.- Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 1723.- Responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva.

(4) **Agravación del tratamiento para el dolo**. Otro principio que aquí interesa es el de la agravación de la responsabilidad en caso de dolo.

(5) **Pacta sunt servanda. Rebus sic stantibus**. El *pacta sunt servanda* emana del *neminem laedere*. Hay en esto un profundo contenido ético: hacer honor a la palabra empeñada; y evitar, mediante el **cumplimiento exacto de la obligación asumida**, que a través de ese incumplimiento se dañe a otro. Para la vigencia del *neminem laedere* no se exige un pacto previo; el *pacta sunt servanda* implica, en cambio, que no hay que “dañar a los demás a través del incumplimiento de la palabra empeñada — con fuerza equivalente a la ley— en la convención de las partes. Pero *pacta sunt servanda* siempre que *rebus sic stantibus*, es decir, **siempre que las cosas sigan siendo así**. Este principio tiene su germen muy remoto en el Derecho Romano.

(6) **Buena fe**. La buena fe puede ser buena fe-creencia, o buena fe-probidad.

Hay **buena fe-creencia** cuando versa justificadamente acerca de la titularidad de un derecho. La apariencia implica el estado objetivo del que deriva el estado subjetivo de la creencia que, cuando es generalizada, se convierte en error común; y *error communis facit jus*.

La **buena fe-probidad** importa el comportamiento leal, el comportamiento honesto, en la celebración y cumplimiento del acto y es, desde otro enfoque, presupuesto del reconocimiento de ciertas facultades, o derechos subjetivos. Es, diríamos, el comportamiento de la gente de bien, de la gente que actúa correctamente

en la convivencia social.

Como RIPERT puede afirmar que la buena fe no produce efectos propios, porque es lo común en la vida jurídica; la mala fe, en cambio, corrompiendo la armonía de la conducta común, tuerce el curso habitual de los fenómenos jurídicos y produce consecuencias comúnmente desvaliosas para quien aporta ese elemento insólito, o inesperado por lo menos, en la convivencia social.

B) ÓRBITAS CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

DESLINDE DE AMBAS

Sabemos que la responsabilidad jurídica juega en dos esferas distintas: la de la responsabilidad penal y la de la responsabilidad civil.

En la responsabilidad civil existen las órbitas contractual y extracontractual, que tienen génesis distintas que condicionan regulaciones más o menos diversas, con diferencias en todo caso apreciables.

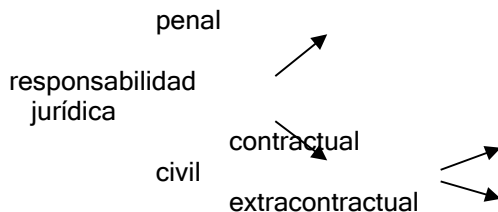
a) La sola circunstancia de que el hombre conviva en sociedad determina que esté sometido a un deber general de no dañar: el *neminem laedere* de los romanos. Este deber de no dañar es genérico, se aplica a las relaciones de los sujetos de Derecho con independencia de que hayan estipulado las pautas de su conducta recíproca; rige por el mero hecho de la convivencia social; es fundamento del ordenamiento jurídico. La violación del deber indicado genera responsabilidad extracontractual. Así, el conductor del automóvil que atropella al peatón le debe la indemnización sin necesidad de que antes del evento dañoso hayan realizado convención alguna.

b) Otras veces las partes recortan su conducta, a través del juego de la voluntad proyectada como acto jurídico contractual: anudan el albedrío y generan obligaciones, que también son susceptibles de incumplimiento.

La responsabilidad es calificable como contractual cuando hay un deber preexistente que es específico y determinado, tanto en relación al objeto como al sujeto obligado (BUSTAMANTE ALSINA): cuando ha sido concretada una obligación de dar, de hacer, o de no hacer algo, como, por ejemplo, cuando D vende a A un equipo de video, queda obligado a entregárselo, y si no cumple, la transgresión de ese deber de entrega genera su responsabilidad contractual.

En cambio, la responsabilidad enrola en el área extracontractual cuando hay un deber preexistente que es genérico (deber general de no dañar), e indeterminado en cuanto a los sujetos pasivos (BUSTAMANTE ALSINA), que viene impuesto por la ley, y que rige por el mero hecho de la convivencia social.

Es decir:



2.- DIFERENCIAS DE RÉGIMEN

Enumeración y análisis.- No obstante la unidad esencial del sistema de responsabilidad, existen diferencias de régimen entre la responsabilidad contractual y la extracontractual o aquiliana.

(1) Génesis. El origen de la responsabilidad contractual es una obligación preexistente que es incumplida; el de la

responsabilidad extracontractual, es la violación de un mero deber no obligatorio .

(2) Estructura. En tanto la responsabilidad contractual sustituye o se adiciona a la obligación preexistente, el deber de resarcir daños y perjuicios a causada un hecho ilícito aquiliano implica una obligación nueva.

(3) Otras diferencias posibles son la extensión de las consecuencias resarcibles, determinación del juez competente, etc.)

C) PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD

Enunciado— La **responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos** :

(1) El **incumplimiento objetivo, o material**, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber general de no dañar,

(2) Un **factor de atribución de responsabilidad** , esto es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo (culpabilidad) u objetivo,

(3) El **daño**, que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible.

(4) Una **relación de causalidad** suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa[fuente] de tal daño.

Claro está que, si la responsabilidad que se reclama del deudor no es la indemnización, sino que se lo ejecuta forzosamente, o se pretende la ejecución por un tercero, el daño y la relación causal resultan indiferentes, pues no se trata de reparar el daño, sino de remedios distintos. Para ello bastan, únicamente, el incumplimiento objetivo y un factor de atribución suficiente; o, dicho de otro modo, alcanza con que el incumplimiento sea jurídicamente relevante.

Virtualidades.— **Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización.**

De allí que la investigación, tendiente a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es o no responsable, deba principiar por analizar si cometió o no una infracción; por ejemplo, si actuó en legítima defensa y no incurrió entonces en incumplimiento alguno, tal investigación debe ser abandonada (Cám. Nac. Civ., Sala E, L.L., 137-851, 23.407-S5].

Si, en cambio, se concluye que hubo infracción, debe estudiarse si promedia un factor de atribución eficaz: por ejemplo, si se precisa culpa, y no la hubo, tampoco habrá responsabilidad.

Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo: verbigracia, quien circula con su automóvil a velocidad excesiva (infracción) y culpablemente (factor de atribución), sin dañar a otro, no es responsable en el sentido de ser deudor de indemnización alguna (S.C.Bs.As L.L., Rep. XXV-437, s. 330).

Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad. Si, por ejemplo, un banco abre una cuenta corriente en infracción de las reglamentaciones, y el titular, mediante el mal uso de esa cuenta, causa dolosamente un daño a un tercero, el banco no es responsable — pese a que hubo infracción atribuible y dañosa— porque no hay relación de causalidad jurídicamente relevante para atribuirle ningún deber de indemnizar al tercero.

D) INCUMPLIMIENTO OBJETIVO

1.- NOCIONES PREVIAS

Concepto.— El incumplimiento objetivo o material consiste en la infracción de un deber; su carácter objetivo deriva de que resulta de una observación previa y primaria del acto, ajena a toda consideración de la subjetividad del agente. De tal manera, verbigracia, el obrar de un loco, que no puede ser culpable por carecer de discernimiento, puede sin embargo resultar objetivamente ilícito.

2.- CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

a) Nociones previas: Se trata de las denominadas causas de justificación que, por consiguiente, excluyen la ilicitud de la conducta en el caso dado.

Concepto.— Ciertas circunstancias justifican una conducta que, de no haber mediado ellas, sería ilícita. Se trata de las denominadas causas de justificación, que excluyen la ilicitud de la conducta en el caso dado.

b) Casos

Ejercicio regular de un derecho.— Es frecuente que los sujetos perjudiquen a otros con su obrar. En los negocios puede suceder que alguien gane y alguien pierda. En el mercado, quien tiene éxito aumenta su clientela, muchas veces a expensas de otro competidor que la pierde.

El Derecho no puede reprochar esas ventajas, en tanto no resulten de una violación de la ley, o de una conducta irregular. Pero, por ejemplo, la obtención de clientela transgrediendo la Ley 22.502 de Lealtad Comercial sería ilícita.

E) RELEVANCIA DEL INCUMPLIMIENTO:

MORA DEL DEUDOR:

1.- CONCEPTO

Mora.— Entendemos por mora **el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante**. Para ello

- deben concurrir **tres requisitos**: (1) dicho incumplimiento; (2) que sea imputable al deudor; (3) que el **deudor esté constituido en mora**.

La demora, o retardo del deudor es, así, un elemento material de la mora, pero no la mora misma. Y puede haber mora, con mayor razón, cuando el deudor no está solamente demorado en su cumplimiento, sino que ha incurrido directamente en inexecución absoluta y definitiva.

Análisis de los elementos.— Nos hemos ocupado recién del incumplimiento material u objetivo.

La imputabilidad del incumplimiento resulta de la existencia de un factor de atribución suficiente.

Y la constitución en mora puede derivar — según los casos — de un acto del acreedor (la interpelación), o del mero transcurso del tiempo.

Formas de interpelar — La interpelación consiste en la exigencia del pago, y puede ser hecha:

(1) Judicialmente, cuando interviene el órgano jurisdiccional; es el caso de la intimación de pago hecha por el oficial de justicia.

(2) Extrajudicialmente, en el caso contrario.

Como la interpelación extrajudicial no es un acto formal, no está sometida a requisito específico alguno: así,

puede ser hecha por escrito o verbalmente, y aun ha sido admitida la eficacia de la efectuada por teléfono. Claro está que, por razones de prueba, conviene llevarla a cabo por un medio susceptible de acreditación ulterior: por acta notarial, con participación de testigos, mediante telegrama colacionado, etcétera.

Requisitos intrínsecos.— Son los relativos a la interpelación misma que — cabe recordar— consiste en la exigencia del pago.

(1) Exigencia categórica. La interpelación no es ruego ni una insinuación; es un requerimiento categórico e indudable, concebido en el modo verbal imperativo,

(2) Requerimiento apropiado. La exigencia del pago debe estar referida a la prestación debida, de la manera en que corresponde que sea llevada a cabo, y en el tiempo propio.

Si el acreedor pide lo que no se le debe, o que el deudor cumpla de manera distinta a la que está obligado, o en otro tiempo que el adecuado, el requerimiento no es apropiado.

(3) Requerimiento coercitivo. Es una derivación de que la interpelación comporte una exigencia de pago.

Si el acreedor efectúa declaraciones, por ejemplo, acerca de que la obligación está vencida, no formula un requerimiento coercitivo, pues no reclama nada.

(4) Exigencia de cumplimiento factible. Es decir, que permita al deudor realizar el cumplimiento, que no sea intempestiva.

(5) Requerimiento circunstanciado. La interpelación, finalmente, debe indicar precisamente las circunstancias del pago (tiempo y lugar) A ellas no fueron establecidas de antemano, o no surgen de la ley.

Requisitos extrínsecos.

(1) Cooperación del acreedor. En las obligaciones en las cuales es preciso que el acreedor coopere para que la prestación del deudor sea factible, aquél no puede requerir útilmente el pago si no ofrece brindar su colaboración.

(2) Ausencia de incumplimiento del acreedor. Este recaudo rige en las obligaciones correlativas pues, en tales casos, “el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva”. Vale decir, por ejemplo, el comprador no podrá exigir al vendedor la entrega de la cosa vendida si, por su parte, ha incumplido su deuda del precio.

4.— EFECTOS DE LA MORA DEL DEUDOR

Enunciado y análisis.— Los efectos de la mora del deudor son varios y de suma trascendencia en orden a su responsabilidad, lo cual explica el esmero con que debe ser tratada la cuestión. Son éstos:

(1) Apertura de las acciones por responsabilidad. Ante la mora del deudor, el acreedor tiene derecho a: I) pretender su ejecución forzada; II) obtener la ejecución por otro; y III) reclamar indemnización.

(2) Indemnización del daño moratorio. El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación. La indemnización del daño derivado del retardo puede ser acumulada.

(3) Imputación del caso fortuito. El moroso soporta el caso fortuito.

(4) Inhabilidad para constituir en mora. En las obligaciones correlativas la parte morosa no tiene derecho a constituir en mora a la otra.

(5) Operatividad de la cláusula resolutoria. En los contratos con prestaciones recíprocas el contratante inocente puede pedir la disolución del vínculo con los daños a cargo del moroso; es decir, la mora de un contratante

autoriza al otro a disolver el contrato.

(6) Facultad de exigir la prestación o la pena. Cuando existe una cláusula penal, el acreedor puede “a su arbitrio” demandar el cumplimiento de la prestación o el pago de la pena, de modo que la mora del deudor autoriza al acreedor a ejercitar esa opción.

(7) Imposibilidad de invocar la teoría de la imprevisión. No se puede argüir la rescisión del contrato cuya obligación se ha hecho “excesivamente onerosa” la parte que estuviese en mora.

El derecho de pagar durante el estado de mora. Principio.— Es indudable que el deudor moroso tiene derecho de pagar, con tal que anexe a la prestación debida los accesorios derivados de la mora (p. ej. los intereses moratorios).

Excepciones— No obstante, hay circunstancias en las cuales el deudor moroso carece del derecho de pagar. Son éstas:

(1) Si el acreedor, fundándose en la mora del deudor, hizo uso de la cláusula resolutoria, con lo cual la pretensión de pagar la deuda emergente del contrato resuelto carecería de causa.

(2) Si la prestación ofrecida por el moroso carece de utilidad para el acreedor, como en los casos de obligaciones con plazo esencial.

6.— CESACIÓN DE LA MORA

Distintas causas— El estado de mora cesa, y concluyen sus efectos, en los siguientes casos:

(1) Si el acreedor renuncia a prevalerse de los efectos de la mora del deudor. Esta renuncia puede ser expresa o tácita, como en el caso en que brinda al deudor una nueva oportunidad de cumplir reiterando la interpelación, o interpelándolo cuando aquél ya estaba automáticamente en mora.

Para evitar los efectos de esta renuncia tácita es preciso, al interpelar al moroso, hacer reserva expresa de no renunciar a los efectos ya generados por su mora, por ejemplo, los intereses ya devengados.

(2) Si el deudor paga o consigna. Cuando paga, se libera inclusive de los accesorios. La consignación tiene virtualidad semejante.

F) FACTORES DE ATRIBUCIÓN

1.— LA NOCIÓN DE CULPABILIDAD

Los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. La culpabilidad, con sus versiones — la culpa en sentido estricto y el dolo —, constituye el sustento subjetivo de la responsabilidad.

El previo análisis de la voluntariedad del acto.— La culpabilidad importa una situación psicológica del sujeto, que se traduce en la omisión de cierta actitud que el Derecho impone a la conducta social.

De ahí que su estudio presuponga el de la imputabilidad moral del acto, esto es, en ámbito civil, de la voluntariedad.

La conducta culpable merece reproche, pero es previo saber si el sujeto, en razón de haber actuado voluntariamente, es reprochable.

El acto voluntario como presupuesto de la culpabilidad.— Los actos voluntarios tienen como componentes el discernimiento, la intención y la libertad. Correlativamente, el obrar humano puede estar fallado en cualquiera de esos elementos.

(1) Obstan al discernimiento la minoridad y la enfermedad mental.

(2) El error o la ignorancia que recaigan “sobre el hecho principal”, sin culpa del autor, así como el error provocado por dolo-engaño, obstan a la intención.

(3) La fuerza irresistible, o el temor fundado de sufrir un mal grave e inminente derivado de injustas amenazas, configuran el vicio de violencia, que obsta a la libertad. Cabe también la violencia de un tercero, que genera responsabilidad para quien la realiza, e inclusive para quien fue sabedor de la fuerza impuesta.

2.- CULPA

a) Concepto

La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Culpa, negligencia e imprudencia.— La culpa proviene de un acto voluntario, es decir, realizado con los necesarios elementos internos: discernimiento, intención y libertad.

Pero en el acto culposo la voluntad del sujeto va dirigida hacia su realización más no a la consecuencia nociva: el daño que se causa en un accidente atribuible al hecho propio culposo deriva, físicamente, de la ley de este orden según la cual dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar en el espacio: pero al Derecho le basta con que el sujeto haya querido el acto para atribuirle la consecuencia dañosa no querida, si su conducta se ha despreocupado del deber social de ajustarla de modo de no dañar injustamente a los demás (*neminem laedere*), a través de la adopción de la diligencia necesaria en cada caso.

La culpa se presenta en dos versiones:

(1) Como negligencia, caso en el cual el sujeto omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso: hace menos de lo que debe.

(2) Como imprudencia, caso en el cual el sujeto obra precipitadamente o sin prever por entero las consecuencias en las que podía desembocar su acción irreflexiva; hace más de lo que debe.

Elementos de la culpa.— La culpa tiene dos elementos, ambos negativos:

(1) Hay carencia de la diligencia debida;

(2) Hay carencia de malicia. Porque si el sujeto obró con intención de no cumplir una obligación contractual, o de dañar extracontractualmente, esos proceder maliciosos configuran dolo, categoría distinta de la culpa y más grave que ella.

d) Prueba de la culpa

Principio.— En principio, el acreedor de la indemnización proveniente de un hecho ilícito — cuando la responsabilidad es subjetiva, esto es, fundada en la culpa— debe probar la culpa de aquél a quien le asigne responsabilidad. En la esfera contractual, de acuerdo con el concepto clásico, el acreedor estaría eximido de esa prueba, pues para liberarse el deudor estaría precisado a demostrar — según fuera— su diligencia o la ruptura de la relación causal.

La razón de ser de que la víctima de un hecho ilícito deba probar la culpa del autor deriva de que invoca la existencia de una obligación nacida con el hecho ilícito pues, antes de ocurrir, existía tan sólo a cargo de aquél el deber general de no dañar. Como la culpa — cuando es el factor de atribución idóneo— constituye un elemento del acto ilícito, debe acreditarla para demostrar su título a la prestación que pretende del sindicado como deudor.

En cambio, en un contrato, como la obligación *stricto sensu* preexiste al incumplimiento, y por lo tanto el acreedor tiene ya título para obtener la prestación, le bastaría acreditar la existencia del contrato, y el deudor, para obtener el rechazo de la pretensión de aquél, debería probar — según los casos—, o que cumplió, o que se liberó por caso fortuito, o que obró sin culpa. Si fallara en esta prueba, resultaría responsable.

Excepciones. Criterio moderno.— Esa regla, en materia de responsabilidad extracontractual, queda de lado cuando el daño se produce con intervención de cosas, pues en algunos casos (daños causados con ellas) se presume la culpa del dueño o guardián y, en otros, se prescinde de la noción de culpa como factor de atribución (daños causados por ellas).

En la esfera contractual — por otra parte— aquella solución tiene vigencia en las obligaciones de resultado, pero no rige en las obligaciones de medios.

e) Culpa de la víctima

Concepto. Virtualidades.— El Código Civil se refiere a la culpa de la víctima, en materia de responsabilidad extracontractual: “El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”.

Es decir: la víctima debe soportar el daño sufrido por ella misma en razón de su culpa. Esta culpa opera como una causa extraña al hecho del autor (concausa), que suprime o desvía el curso de los sucesos y genera una relación causal propia que resulta ajena a la responsabilidad de dicho autor.

451. Aceptación de riesgos.— En ciertas circunstancias la aceptación de riesgos por parte de la víctima incide sobre su derecho a la indemnización. Pero, para esclarecer la cuestión, es menester formular estos distingos, de acuerdo con el criterio de ORGAZ:

(1) Hay aceptación impropia de riesgos cuando una persona asume un peligro del que nadie es particularmente responsable: una operación quirúrgica, un partido de rugby.

En estos casos, el someterse a tal riesgo impropio no configura culpa, y si el cirujano o el jugador de rugby — en esos ejemplos— causan un daño por culpa, no cabrá limitar la responsabilidad, que les compete.

(2) Hay, por lo contrario, aceptación propiamente dicha de riesgos cuando la víctima asume el peligro inherente a la cosa o la actividad ajena que le produce el daño.

Por ejemplo, si se somete a una operación quirúrgica innecesaria y riesgosa, o sube a un automóvil conducido por un ebria, o utiliza una escalera ajena que está manifiestamente deteriorada. En tales casos hay cierta dosis de culpa de parte del aceptante del riesgo, que excluye o disminuye su derecho a la indemnización.

f) Culpa concurrente

Concepto.— Hay culpa concurrente cuando se conecta la culpa del damnificado con la del autor del hecho.

No se debe confundir la concurrencia de causas con la concurrencia de culpas: por ejemplo, en un choque de vehículos, si uno sola de los conductores es culpable, habrá concurrencia de causas pero no de culpas (Cám. Nac. Fed., L.L., 122-487). Habiendo culpa tanto del autor como de la víctima, una de esas culpas puede haber sido indiferente:

por ejemplo, si alguien embiste por torpeza propia un automóvil mal estacionado, sólo es relevante la culpa del embistente (S.C.Bs.As Rep. L.L., XXV 11-478, s. 59). Y si ambas culpas derivan la una de la otra — es decir, no son autónomas— tampoco habría concurrencia de culpa: es el caso del pasajero de un automóvil que, aterrorizado por la velocidad que el conductor le ha impuesto, se arroja a la calle; si el daño que sufre el pasajero está determinado exclusivamente por la culpa del conductor, su propia culpa es también irrelevante (ORGAZ).

3.— DOLO

a) Concepto

Distintas acepciones.— El dolo es otro factor subjetivo de atribución.

Tiene distintas acepciones, dos de las cuales surgen de definiciones del Código Civil, y una tercera deriva de la interpretación doctrinaria.

(1) Como vicio de la voluntad se trata del dolo-engaño: acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin. Se trata, pues, de la acción de un sujeto que provoca error en el otro, y destruye así su voluntad jurídica.

(2) Como elemento del delito civil según el cual el delito civil es el hecho ilícito cometido "a sabiendas y con intención de dañar".

(3) Como causa de incumplimiento contractual, que compromete la responsabilidad del deudor doloso, no está definido. Se interpreta que consiste en la intención deliberada de no cumplir (contra: SALVAT y DE GÁSPER para quienes también en este caso sería necesaria la intención de dañar). En tal especie de dolo el querer jurídicamente relevante se endereza hacia no cumplir, pudiendo hacerlo: no es menester – a diferencia del delito civil – que haya intención de dañar, pero, claro está, si el incumplidor contractual quiere el daño, actúa a fortiori con dolo.

Quid de la malicia. – Se introduce la idea de inejecución maliciosa.

En nuestro modo de ver se trata de la misma inejecución deliberada, configurativa del dolo en el incumplimiento contractual. La malicia en el incumplimiento contractual, dentro del género de la mala fe, consiste pues en la inejecución deliberada de la deuda (contra: BORDA y MOSSETITURRASPE para quienes sería menester la intención de dañar).

4.– TEORÍA DEL RIESGO

a) Concepto

Versiones.– La teoría del riesgo constituye el soporte fundamental de la atribución objetiva de responsabilidad en el momento actual.

a) Una comprensión, la del riesgo provecho, pone los daños a cargo de quien obtiene ventajas de la realización de cierta actividad (ubi emotumentum ibi onus).

b) Otra, la del riesgo creado, va más allá: se independiza de la idea de aprovechamiento económico, y considera bastante la introducción del elemento con aptitud para dañar a los fines de asignar el deber de resarcir a quien con él creó el riesgo.

b) Penetración en el Derecho argentino

Distintos dispositivos legales.– La teoría del riesgo penetró en el Derecho argentino a través de varias leyes:

(1) El Código Aeronáutico de 1954 (ley 14.3071, reemplazado por ley 17.285, según el cual el explotador o quien usa la aeronave es responsable "con sólo probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o de una cosa caída o arrojada de la misma o del ruido anormal de aquella" (art. 155, ley 17.285).

(2) La Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, aprobada por ley 17.048, cuyo artículo IV, parte I, establece categóricamente el carácter objetivo de la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear destinada a fines pacíficos.

(3) Art. 1722 del CCyCN. "Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario".

La noción de solidaridad: seguro, fondos de garantía, seguridad social, etc.— Las ideas contemporáneas preconizan, como mecanismo idóneo para posibilitar la realización individual en el contorno social, un criterio solidarista. Desentenderse de la desgracia ajena, en cambio, traduce egoísmo.

a) El seguro es un instituto adecuado a la idea solidarista; el asegurado, mediante el pago de una prima, obtiene que el asegurador cubra el daño que él sufre; y como esa reparación se solventa mediante el pago de la masa de primas, el daño individual resulta distribuido entre todos los asegurados.

Eso explica — entre otras razones— la difusión actual del seguro, que resguarda a la víctima de la eventual, y bastante común, insolvencia de quien debiera soportar la reparación del daño. Por lo dicho, no se trata meramente de hallar sujetos a quienes endosarles el deber de reparar el daño, sino de que la víctima pueda reclamarla a alguien solvente. Por cierta que el Derecho no puede lograr que todos los causantes de daños sean solventes, pero sí puede imponer el seguro forzoso para ciertas actividades máximamente peligrosas (daños nucleares, art. VII, ap. 1 de la Convención de Viena), o para otras que, estadísticamente, tienen gran operatividad en la generación de perjuicios: caso de los daños causados por automotores.

b) La importancia del seguro ha sido encomiada reiteradamente, sosteniéndose la necesidad de seguros obligatorios para el desarrollo de múltiples actividades, como los que existen para el caso de muerte de trabajadores en relación de dependencia, o para los accidentes nucleares.

G) DAÑO

1.— CONCEPTO

Sentidos amplio y estricto.— El concepto daño puede ser comprendido con dos significados de distinta extensión:

(1) En sentido amplio, hay daño cuando se lesiona cualquier derecho subjetivo;

(2) En sentido estricto, la lesión debe recaer sobre ciertos derechos subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera — en determinadas circunstancias— una sanción patrimonial. Este último significado es relevante en materia de responsabilidad civil.

El daño en sentido estricto es pues **la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho subjetivo, que genera responsabilidad**. En la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento, y en el campo extracontractual no hay acto ilícito punible si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, sea que recaiga sobre un objeto exterior, o bien se confunda con la existencia de la persona.

2.— ESPECIES

Actual y futuro. — Daño actual o presente es el ya ocurrido al tiempo en que se dicta la sentencia (ORGAZ; C.S. Mendoza, L.L., 135-131).

Daño futuro, por lo contrario, es el que todavía no ha sucedido, aunque su causa generadora ya existe. Puede ser: (1) cierto, que es el que se presenta como indudable o con un alto margen de probabilidad (p. ej. la privación de ulteriores ganancias de un viajante de comercio a causa de su incapacidad); o (2) incierto, que es el eventual, hipotético o conjetural.

Patrimonial y extrapatrimonial.— El daño es patrimonial cuando repercute en el patrimonio, de manera directa o indirecta: “Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades”. Sobre otra concepción del daño indirecto.

El daño extrapatrimonial o moral, en cambio, se caracteriza por su proyección moral, sea que el hecho generador lesione un derecho subjetivo patrimonial o extrapatrimonial, pues “si lo que se quiere clasificar es el daño resarcible, no hay por qué atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo, esto es a

los efectos o consecuencias de la lesión" (ORGAZ).

El daño patrimonial comprende: (1) el daño emergente (pérdida sufrida) y (2) el lucro cesante (ganancia dejada de percibir).

Por otra parte, el daño moral aparece como género de una categoría específica: el agravio moral, que se configura cuando el daño moral es causado con dolo, "es decir con conocimiento del mal moral que se podía producir, y que de hecho se habría producido" (LLAMBÍAS).

Daño a la persona.— La persona es un proyecto de vida (FERNÁNDEZ SESSAREGO), todo lo que afecte a ese proyecto configura daño a la persona. Se lo denomina también daño no patrimonial, biológico, a la salud, extraeconómico, a la vida de relación, inmaterial, a la integridad sicosomática, no material.

H) CAUSALIDAD

1.— LA CAUSA EFICIENTE

Concepto.— Desde que causa es lo que provoca el efecto, la expresión causa eficiente es, en realidad, tautológica. Sin embargo su uso es generalizado, y conviene mantenerlo, para designar la relación que existe entre un hecho (el incumplimiento) y los resultados que de él derivan. Porque no todas las derivaciones de un hecho son atribuibles al sujeto, sino sólo algunas de ellas imputadas con la perspectiva de Justicia. Piénsese, por ejemplo, si podría cargarse a la responsabilidad del sastre, que se retrasó en la entrega de la ropa encargada, el accidente de tránsito que sufre un cliente cuando debe volver a su taller para retirarla en una fecha posterior a la que se había convenido originariamente. En tal caso hay un daño remoto y el Derecho, a pesar de que sea una derivación del incumplimiento, no lo imputa al incumplidor.

Antecedentes.— Para el planteamiento general de la teoría de la causa.

La incorporación de la teoría de la relación de causalidad al terreno jurídico en materia de responsabilidad es relativamente reciente, y fue antecedida poco antes por las investigaciones de los penalistas; porque los civilistas han aducido muchas veces que es insoluble, o que es suficiente valerse del sentido común, o "del sentimiento" (MAZEAUD-TUNC) para dar respuesta al interrogante qué daños se imputan; o quizá porque "las aguas de la Filosofía están muy cerca" (POLLOX).

CONCURRENCIA DE VARIAS LA PRODUCCIÓN DEL RESULTADO

La concausa.— La operatividad de una causa puede ser desplazada o desviada por otra que actúe junto con ella; en tal caso existe una concausa. Es lo que ocurre, verbigracia, en el supuesto de la culpa concurrente de la víctima que opera como concausa del daño.

Si la causa que se interpone suprime los efectos de otra causa y genera una nueva relación causal — es decir, si no concurre con ella — se trata de una causa nueva, y no de una concausa en el sentido expresado.

La teoría de la indiferencia de la concausa.— Esta teoría asigna la totalidad del resultado a cada una de las concausas, con lo cual viene a coincidir con la *condictio sine qua non*.